

刑法
No241

共通問題 H27-8

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 準強制わいせつ罪（刑法第178条第1項）の「心神喪失」とは、責任能力における心神喪失と同義である。（解答不能）
- イ. 第三者の暴行・脅迫によって相手方が「抗拒不能」の状態に陥っているのを利用して、同人を性交等した場合、準強制性交等罪（刑法第178条第2項）が成立する。（解答不能）
- ウ. 2名以上の者が、不同意性交等する目的でそれぞれ暴行を加えて相手方の同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にした上、犯行現場にいる者のうち1名が性交等行為に及んだ場合、不同意性交等罪（刑法第177条）の共同正犯が成立する。（改）
- エ. 不同意性交等する目的で暴行を加えたところ、その暴行によって相手方が死亡したため、性交等するに至らなかった場合、不同意性交等致死罪（刑法第181条第2項）が成立する。（改）
- オ. 女子に対して準強制わいせつ罪に当たる行為をし、同人に騒がれて捕まりそうになり、わいせつな行為を行う意思を喪失してその場から逃走するため同人に暴行を加えて傷害を負わせた場合、強制わいせつ致傷罪（刑法第181条第1項）は成立せず、準強制わいせつ罪と傷害罪が成立する。（解答不能）

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

* 令和5年刑法改正により、準強制わいせつ及び準強制性交等罪（旧刑法178条）が削除されたため、本記述ア、イ、オは解答不能となった。また、同改正により、強制性交等罪は「不同意性交等罪」（177条）、強制性交等致死罪は「不同意性交等致死罪」（181条2項）に改められた。そのため、本記述ウ及びエを改題した。

No241	わいせつの罪		正答率 71%
共通H27-8	正解	解答不能	

ア 解答不能

令和5年の刑法改正により、強制わいせつ罪(旧176条)、準強制わいせつ罪(旧178条)は、不同意わいせつ罪(176条)に改められ、強制性交等罪(旧177条)、準強制性交等罪(旧178条)は、不同意性交等罪(177条)に改められた。改正前の「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」の要件は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という表現を用いて統一的な要件に改正され、その原因となり得る行為や事由について具体的に挙げることとされた(176条1項各号参照)。これは、要件の解釈により犯罪の成否の判断にばらつきが生じないようにしたためと説明されている(法務省HP)。この結果、記述アは、解答不能となった。

イ 解答不能

上記アに記したように、令和5年の刑法改正により、準強制性交等罪(旧178条)は、不同意性交等罪(177条)に改められ、条文上「抗拒不能」が無くなったため、記述イは、解答不能となった。なお、本記述の主旨は、性交等の目的で被害者の抵抗困難な状態を作出した行為者だけでなく、その状態を利用して性交等をした者にも同罪が成立するというものである。

ウ 正しい

不同意性交等罪の共同正犯の成立には、2人以上の者が共同していることが必要である。もっとも、本罪の成立には、必ずしも複数の者が性交等行為に及ぶことを必要としない。よって、不同意性交等罪の共同正犯が成立する。

エ 正しい

不同意性交等致死傷罪(181条2項)は、不同意性交等罪(177条)又は不同意性交等未遂罪(180条、177条)等を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する。そして、不同意性交等罪の着手時期は、性交等の手段となる暴行又は脅迫を開始した時点である。本記述では、不同意性交等する目的で暴行を加えた時点で、不同意性交等罪の着手が認められ、不同意性交等未遂罪が成立する。そして、その暴行によって相手方が死亡しているので、性交等の有無にかかわらず、不同意性交等致死罪が成立する。

オ 解答不能

本記述では、女子に対して準強制わいせつ罪(旧178条1項)に当たる行為をし、同人に騒がれて捕まりそうになり、その場から逃走するため同人に暴行を加えて傷害を負わせている。この暴行が準強制わいせつ行為に随伴するものといえるか、これによって生じた傷害結果について強制わいせつ致傷罪(旧181条)が成立するかが問題となり、最決平20.1.22(百選Ⅱ15事件)は、強制わいせつ致傷罪の成立を認めた。令和5年改正法後は、181条(不同意わいせつ等致傷罪)が成立するか、当該暴行が不同意わいせつ行為に随伴するものといえるかを同様に考えることができるが、この問いの前提としては、準強制わいせつ罪(旧178条1項)、強制わいせつ罪(旧176条)、強制わいせつ等致死傷罪(旧181条)という条文構造があることから、解答不能とした。